

<제01장 노동법 총론.제06절 근로기준법상 사용자>

<제09장 비정규근로자.제03절 파견근로자>

[기출][1][2020-1-1]명목상 외주업체 소속 근로자의 실질적 사업주 판단 기준

《【문제1】 A공사는 고속국도의 설치·관리 및 통행료 수납업무를 수행하는 공기업이다. 개인사업자 B는 2018. 6. 30. A공사에서 정년퇴직한 자로서, 2018. 12. 31. 수의(隨意)계약 방식으로 A공사와 통행료 수납업무에 관한 용역계약을 체결하였다(계약기간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.). B는 용역업체의 창업에 소요된 5천만 원 전액을 A공사로부터 연 1%의 이자율로 차입하여 조달하였고, 별도의 사무실을 두지 않았으며, 용역계약에 따라 A공사의 영업소에서 근무할 수납원 외에는 다른 근로자를 채용하지 않았으며, 2020. 8. 15.까지 A공사 이외의 거래처에서 발생한 매출은 없다. B는 용역계약의 이행을 위하여 2019. 1. 1. A공사로부터 소개받은 甲과 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하였다. 甲은 채용과 동시에 A공사가 관리하는 ○○영업소의 통행료 수납원으로 발령받아 계속 근무하고 있다.

한편, C사는 시설관리 등을 사업목적으로 2000. 1. 1. 설립된 회사로서 2020. 8. 15. 현재 자본금은 5억 원이며, 다수의 거래처로부터 시설관리 등의 업무를 도급받아 수행하고 있다. 다만, C사는 근로자파견사업의 허가를 받지 아니하였다. C사는 2017. 12. 31. 공개입찰 방식으로 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.의 1년의 계약기간으로 A공사와 통행료 수납업무 용역계약을 체결하였고, 이후 같은 방식으로 두 차례 계약을 갱신하였다. C사는 기존에 근무하던 수납원이 퇴직하여 결원이 생기자 구직자를 모집하여 2019. 8. 14. 乙과 1년의 계약기간으로 근로계약을 체결하였다. 乙은 채용과 동시에 A공사가 관리하는 △△영업소의 통행료 수납원으로 발령받아 근무하던 중 2020. 8. 13. 계약기간이 만료되어 C사에서 퇴사하였다. C사는 乙에게 기존과 동일한 조건으로 근로계약을 갱신할 것을 제안하였으나, 乙은 'A공사에게 나를 직접 고용하라고 요구하겠다.'며 그 제안을 거절하였다.

A공사는 사전에 정해 둔 용역대금 산정기준에 따라 B 및 C사 등 외주업체와 용역계약을 체결하였고, A공사의 영업소는 A공사의 직원인 소장, 과장, 대리, 주임과 외주업체 소속인 수납원으로 구성되어 있다. 수납원들은 A공사의 영업소 사무실로 출근하여 A공사의 로고가 새겨진 근무복과 명찰을 착용한 후 주임으로부터 지시사항을 전달받고 요금소로 이동하여 통행료 수납업무 등을 수행하였다. 또 수납원들은 교대시간 또는 근무시간 종료 후 사무실로 이동하여, 징수한 통행료를 확인한 후 주임에게 입금확인서와 개인별 근무확인서를 작성·제출하였고, 주임은 이러한 개인별 근무확인서의 내용이 A공사의 전산시스템에 자동 저장된 정보와 일치하는지 확인하고 소장의 결재를 받았다. 한편, 외주업체들은 영업소 소장에게 매월 소속 수납원들의 근무편성표, 출퇴근 사항을 보고하였다. A공사는 2018. 1. 1. 통행료 수납업무와 관련하여 고객을 응대할 때의 행동, 표정, 언어, 예절, 자세, 예외적 상황별 고객 응대 요령 등이 기재된 매뉴얼을 제작하여 외주업체에 배포하였고, 외주업체 소속 수납원들은 이러한 매뉴얼에 따라 업무를 수행하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲은 자신이 A공사에 직접 채용된 근로자라고 주장한다. 판례법리에 근거하여 甲의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음1> 명목상 외주업체 소속 근로자의 실질적 사업주 판단 기준

I. 문제의 제기

- 사안에서 A공사가 외주업체 B와 용역계약을 체결하고 B와 근로계약을 체결한 甲을 A공사의 영업소에서 통행료 수납원으로 근무하게 하면서 업무수행 과정 전반에 관여하는 상황이다. 쟁점으로 <외형상 용역업체 소속 근로자인 甲이 실질적으로 A공사와 직접 근로계약관계가 인정되는지> 위장도급 또는 묵시적 근로계약관계에 관한 판례 법리를 중심으로 검토할 필요가 있다. 이하에서는 묵시적 근로계약관계의 성립 요건과 甲과 A공사 사이의 직접 고용관계 인정 여부를 논한다.

II. 묵시적 근로계약관계 성립에 관한 법리

1. 성립 요건 및 판단 기준★

- “판례”는 원고용주에게 고용되어 제3자의 사업장에서 제3자의 업무에 종사하는 자를 제3자의 근로자라고 할 수 있으려면, 원고용주는 사업주로서의 독자성이 없거나 독립성을 결하여 제3자의 노무대행기관과 동일시 할 수 있는 등 그 존재가 형식적·명목적인 것에 지나지 아니하고, 사실상 당해 피고용인은 제3자와 종속적인 관계에 있으며, 실질적으로 임금을 지급하는 자도 제3자이고, 또 근로제공의 상대방도 제3자이어서 당해 피고용인과 제3자 간에 묵시적 근로관계가 성립되어 있다고 평가될 수 있어야 한다고 판시하고 있다. 이와 관련하여 다음과 같은 요건을 종합적으로 고려하여 판단한다.

(1) 사업주로서의 독자성 및 실체 결여

- 원고용주가 사업주로서의 외형을 갖추고 있더라도, 독자적인 자금이나 설비가 없고, 자기의 책임과 계산으로 사업을 운영하지 않으며, 사업주로서의 실체가 없는 등 그 존재가 가공적인 경우이다.

(2) 실질적인 지휘·감독권의 행사

- 원고용주가 근로자에 대한 채용, 해고, 임금 지급, 징계 등 인사노무관리권을 행사하지 않고, 실제로는 제3자가 근로자의 근로조건을 결정하며, 업무수행 과정에서 직접 지휘·감독을 행사하여 실질적인 노무 제공의 상대방이 제3자인 경우이다.

2. 법적 효과

- 묵시적 근로계약관계가 인정되면, 형식적인 근로계약 관계에도 불구하고 근로자와 실질적인 사용자(사용사업주) 사이에 직접 근로관계가 존재하는 것으로 간주된다. 이 경우 근로자는 실질적인 사용자(사용사업주)를 상대로 임금 청구, 고용 유지 보장 등을 요구할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 외주업체 대표 B의 사업주로서의 실체성 검토

(1) 자금 및 자산의 종속성

- 개인사업자 B는 용역업체 창업 자금 5천만 원 전액을 A공사로부터 매우 낮은 이자율(연 1%)로 차입하여 조달하였다. 이는 자금 조달에 있어 A공사에 전적으로 의존하고 있음을 보여준다.

(2) 사업 인프라의 부재

- B는 별도의 사무실을 두지 않았다. 이는 독자적인 사업 시설을 갖춘 사업자로 보기 어렵게 만드는 요소 중 하나이다.

(3) 경영상의 독립성 결여

- B는 A공사의 퇴직자로서 수의계약 방식으로 용역권을 부여받았으며, 2020. 8. 15.까지 A공사 외의 거래처가 전혀 없어 매출의 100%를 A공사에 의존하고 있다. 또한, 수납원 외에 다른 근로자를 채용하지 않았고, 甲 또한 A공사로부터 소개받아 채용하는 등 채용 과정에서도 독자성이 결여되어 있다.

2. A공사의 실질적 지휘·감독권 행사 여부

(1) 업무 수행의 지시 및 통제

- 수납원들은 A공사의 로고가 새겨진 복장을 착용하고, A공사 소속 직원(주임)으로부터 직접 지시사항을 전달받았다. 업무 종료 후에도 A공사 직원에게 보고서를 제출하고, 전산시스템을 통해 확인을 받는 등 업무 수행 과정 전반이 A공사의 직접적인 통제하에 있었다.

(2) 인사관리의 실질적 지배

- 외주업체들은 수납원들의 근무편성표와 출퇴근 사항을 A공사 소속 영업소장에게 보고하였다. 이는 외주업체가 독자적으로 인사권을 행사하는 것이 아니라 A공사의 관리 체계 안에서 종속적으로 인력을 운영했음을 의미한다.

(3) 매뉴얼을 통한 구체적 통제

- A공사가 제작하여 배포한 매뉴얼은 단순한 가이드라인을 넘어 행동, 표정, 언어, 예절 등 매우 구체적인 업무 수행 방식을 규정하고 있다. 수납원들이 이에 따라 업무를 수행한 것은 A공사가 업무의 내용과 방식을 결정했음을 보여준다.

IV. 결론

- 사안의 개인사업자 B는 자금, 시설, 고객 확보 등 모든 측면에서 A공사에 전적으로 종속되어 있어 사업주로서의 독자성과 실체를 갖추지 못한 명목상의 사업주에 불과하다. 또한, 실질적인 업무 지휘·감독권과 인사관리권 역시 A공사가 행사하고 있음이 명백하다. 따라서 판례의 묵시적 근로계약관계 성립 법리에 따라 甲은 형식적인 계약 상대방인 B가 아니라 실질적인 사용자인 A공사와 직접적인 근로계약관계에 있다고 보아야 한다. 결론적으로 자신이 A공사에 직접 채용된 근로자라는 甲의 주장은 타당하다.